

1501490-34.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata Marques de Jesus

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... RECORRIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. TESTEMUNHO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. PRECEDENTES. 1. Não há violação do art. 619 do Código de Processo Penal quando o Tribunal de a quo explicita, de forma clara e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

1ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Jardim Francisco Morato, Francisco Morato - SP - cep 07910-220

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501490-34.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2156976/2022 - DEL.POL.PLANT FRANCISCO MORATO, 25465462 - DEL.POL.PLANT FRANCISCO MORATO, 2156976 - DEL.POL.PLANT FRANCISCO MORATO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEITON DOS SANTOS SILVA e outro

Data da Audiência:

14/09/2022

Réu Preso

Aos 14 de setembro de 2022, às 13 horas e 45 minutos, nesta cidade de Francisco Morato, na sala de audiências do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Francisco Morato, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito Dra. Renata Marques de Jesus, comigo escrevente abaixo assinado. Presente representante do Ministério Público Dr. João Paulo Robortella, foi aberta audiência de instrução e interrogatório, realizada no formato virtual (por videoconferência) ou misto, nos termos já estabelecidos pela Corregedoria Geral da Justiça, conforme artigo 8º do Provimento CSM/TJSP nº 2.651 de 16/03/2022, nos autos da ação e entre as partes supra referidas. Aberta com as formalidades legais e apregoadas as partes, restaram: AUSENTE o réu CLEITON DOS SANTOS SILVA; PRESENTES o réu GUSTAVO TORRES DOS SANTOS, seu advogado nomeado Dr. Alexandre Pinheiro Brevilieri e as testemunhas Marcio Eric Alves Feitoza e Pablo Carlos Renteiro, as quais foram

ouvidas. Terminada a(s) inquirição(ões), foi colhido o interrogatório do réu presente, Gustavo. O(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) através do Microsoft Teams, arquivado(s) na plataforma One Drive e não será(ão) transcrito(s) em papel (Provimento 8/2011 da Egrégia Corregedoria da Justiça), permitindo aos procuradores o acesso a qualquer tempo, que constitui, nos termos do art. 405, § 1º e 2º do CPP, meio idôneo de documentação e se destina a obter maior fidelidade das informações. Pelo(a) MM.(a) Juiz(a) de Direito foi dito: Tendo em vista que o corréu Cleiton mudou-se sem informar o Juízo (fls. 118 e 162) e não atendeu às ligações feitas ao número de telefone por ele informado nos autos (fls. 118), declaro-o REVEL. No mais, considerando que as partes não postularam novas diligências, declaro encerrada a instrução. Passo a palavra ao representante do Ministério Público para alegações finais, seguido pela Defesa. Pelo Ministério Público foi dito: "MM. Juiz(a), CLEITON DOS SANTOS e GUSTAVO TORRES DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas). Os acusados foram notificados (fls. 115 e 117/118) e apresentaram defesa prévia (fls. 122). A denúncia foi recebida em 10 de agosto de 2022 (fls. 130/132). Em audiência de instrução, foram ouvidas em audiências as testemunhas arroladas nos autos, procedendo-se aos interrogatórios dos réus. Assim, vencida a fase instrutória, a pretensão punitiva deve ser julgada procedente. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, por meio do laudo de constatação preliminar de fls. 41/46, e laudo exame químico- toxicológico de fls. 170/172. A autoria é inequívoca, comprovada pelo auto de prisão em flagrante e pela prova oral produzida. A testemunha Marcio Eric Alves Feitoza policial militar, narrou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento e verificou dois sujeitos em atitude suspeita, com mudança súbita de comportamento. Eles estavam juntos e tentaram correr juntos da viatura policial, mas foram detidos. Efetuada a abordagem, foram localizadas algumas porções de entorpecentes com GUSTAVO e CLEITON e certa quantia em dinheiro. Indagado, GUSTAVO disse que estava traficando, que CLEITON trabalhava com ele e admitiu que em sua residência, que se localizava há poucos metros, haviam mais drogas. Foi feita vistoria na residência e, em uma sacola que estava em cima da cama, foram encontradas grandes porções de drogas variadas. Na residência também havia mais dinheiro e dois rádios comunicadores. Somente foi possível localizar as drogas na residência porque GUSTAVO colaborou. Havia objetos pessoais de GUSTAVO no local, indicando que ele morava naquela casa. No mesmo sentido foi o testemunho do policial militar Pablo Carlos Renteiro. Com efeito, as testemunhas de acusação corroboraram os fatos descritos na denúncia. Em seu interrogatório, o réu GUSTAVO confessou a prática do delito. Já o corréu CLEITON, em que pese ter sido regularmente citado e intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo declarada sua revelia. Ressalte-se que os agentes de segurança, na qualidade de agentes públicos, gozam de fé pública e não há nenhum elemento nos autos a abalar sua credibilidade. Pelo contrário: tais depoimentos se mostraram em consonância com o restante da prova produzida. Seus testemunhos, portanto, possuem pleno valor probatório, tanto que estão sujeitos ao crime de falso testemunho, conforme orientação da jurisprudência: TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o édito repressivo, como pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente. 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014, os destaques não são do original); PENAL. PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO.

INEXISTÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. TESTEMUNHO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. PRECEDENTES. 1. Não há violação do art. 619 do Código de Processo Penal quando o Tribunal de a quo explicita, de forma clara e fundamentada, os elementos de sua convicção. Na hipótese, a Corte de origem enfrentou todas as omissões apontadas nos aclaratórios opostos pela defesa. 2. O exame da pretensão recursal no sentido da ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar a conduta de tráfico e associação para o tráfico, implica a necessidade de revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos. Incidência da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014, os destaques não são do original). Ademais, já asseverou o Desembargador José Renato Nalini: "é valioso o depoimento de policiais em hipóteses como a presente. O agente da segurança é recrutado mediante concurso público para atuar em prevenção e repressão à criminalidade e não é sensato negar-lhe crédito quando, perante o mesmo Estado que o contratou, relata atos de ofício. É compromissado como qualquer outra testemunha e a circunstância de inexistir pessoa não pertencente aos quadros policiais para depor é justificável. Seria até perigoso envolver cidadãos que não são remunerados para reprimir a criminalidade em diligências potencialmente vulneradoras de irrecuperáveis bens da vida como a narrada nestes autos" (TJSP - Autos de Apelação nº 141.299-3/3 - Segunda Câmara - v.u.). O propósito da traficância é certo, haja vista: (1) a natureza, diversidade e a considerável quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas; (2) a forma de acondicionamento das substâncias em diversas porções individuais, prontas para entrega ao consumo de terceiros; (3) o local da abordagem, já conhecido como ponto de tráfico; (4) a quantia em dinheiro encontrada, produto do comércio das drogas; (5) os dois rádios comunicadores encontrados; e (6) a confissão do acusado GUSTAVO. Assim, comprovou-se de forma inequívoca a prática do delito em apreço, bem como a tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade dos fatos imputados aos acusados, impondo-se, desta feita, as suas condenações. Passa-se, então à análise da pena a ser aplicada. Na primeira fase de dosimetria da pena, atentando-se aos parâmetros do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, deve a pena-base ser fixada acima do mínimo legal, ante a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (3 diferentes espécies, totalizando quase meio quilo), dentre elas o crack, de altíssima lesividade, que possui rápido efeito e grande potencial de vício, cuja traficância vem destruindo famílias e causando sérias consequências à sociedade, o que deve ser considerado para fins de individualização da pena. Na segunda fase, incide, a atenuante da confissão espontânea em favor do corréu GUSTAVO. Na terceira fase, inviável a concessão do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, diante das circunstâncias concretas do caso, na medida em que os réus utilizavam uma residência para armazenar imensa quantidade de entorpecentes (quase mil "pedras" de crack, além de outras porções de "maconha" e cocaína, bem como quantia em dinheiro e dois rádios comunicadores), demonstrando que não se tratam de traficantes meramente eventuais, reais destinatários do benefício, mas sim de pessoas que se dedicam de forma profissional a essa atividade, caso contrário não lhes seria confiada tão valiosa "mercadoria" deste meio ilícito. Vedada a conversão em pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 da Lei nº 11.343/06, valendo destacar que se trata de delito equiparado a hediondo, a demandar maior rigor em sua reprimenda, por força de expresse mandado constitucional de criminalização. Ante o exposto,

o Ministério Público requer seja julgada procedente a pretensão punitiva, com a consequente condenação de CLEITON DOS SANTOS e GUSTAVO TORRES DOS SANTOS, nos exatos termos da denúncia. Com o trânsito em julgado, requer-se o perdimento do dinheiro apreendido em favor da União, emitindo-se a respectiva guia, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06 (fls. 83)". Pela Defesa foi dito: "MM. Juiz(a), Ultimada a instrução, o Representante do Ministério Público, imbuído nos elevados

critérios de justiça, entendendo comprovados a autoria e materialidade delitiva, pugna pela total procedência da denúncia e consequentemente a condenação do réu. A defesa por seu turno discorda com a posição do nobre representante ministerial, tendo em vista que, na audiência de instrução os Réus demonstraram muita sinceridade e firmeza em suas declarações. Destarte, porém, independentemente de toda presunção negativa existente sobre os acusados, infelizmente nem tudo é possível de se provar ao contrário, mas, vale salientar que o réu não foi flagrado cometendo o crime em questão, é primário e possui bons antecedentes, não tendo motivos para envolver-se em qualquer tipo de ilícito. Ademais, tudo leva a crer que os acusados não praticaram o ilícito em questão, eis que, a versão alegada pela acusação e as provas colhidas são totalmente insuficientes a demonstrar sua autoria, além do que, vale lembrar o réu não ostenta antecedentes criminais e é primário, por tais razões, a r. denúncia deve ser julgada totalmente improcedente. O Policial Militar Pablo afirma ter encontrado em posse dos réus pequenas dozes, contudo, o Réu Gustavo informou haver outras "mercadorias" em sua residência levando os policiais até o local e ainda indicando o local onde estava guardado, esclarece ainda, que só chegaram na residência por conta da indicação do próprio Réu. O Policial Militar Marcio repetiu a narrativa de seu colega. O Réu confessa o crime a ele imputado aduzindo estar passando necessidades, e se arrepende de seus atos. Assim sendo, considerando a precariedade das provas e inexistindo elementos seguros para sustentar a imputação inicialmente formulada, requer a improcedência da r. denúncia e a consequente absolvição do acusado com base no artigo 386, inciso VI do Código de Processo Penal por absoluta fragilidade do conjunto probatório, ou considerando a confissão, seja aplicada a pena em seus mínimos legais considerando serem os Réus primários e de bons antecedentes, além de terem confessado.". Em seguida foi proferida a sentença pelo(a) MM.(a) Juiz(a) de Direito: "Vistos. GUSTAVO TORRES DOS SANTOS e CLEITON DOS SANTOS SILVA, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da lei nº 11.343/06, porque no dia 08 de junho de 2022, por volta das 12h44, na Rua Cairo, altura do nº 87, Jardim Santa Rosa, cidade e comarca de Francisco Morato, traziam consigo, para fins de tráfico, 4 porções de "maconha" (cannabis Sativa L.) e guardavam, também para fins de tráfico, 142 (cento e quarenta e duas) porções de "maconha" (cannabis Sativa L.), com peso líquido aproximado de 308g (trezentos e oito gramas), 15 (quinze) porções de cocaína, com peso líquido aproximado de 7g (sete gramas) e 952 (novecentos e cinquenta e duas) porções de crack, com peso líquido aproximado de 123g (cento e vinte e três gramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls.1/3). Em audiência de custódia foi convertida em preventiva a prisão em flagrante de GUSTAVO e concedido benefício da liberdade provisória a CLEITON (fls. 62/66). Notificados, os réus apresentaram defesa prévia (fls. 122), e a denúncia foi recebida (fls. 130/132). Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu presente foi interrogado. Mídias arquivadas. Em debates o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, observando a não aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11343/06. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição ou, então, fixação de pena mínima considerando a primariedade e confissão. É o relatório. Fundamento e decido. À luz das provas carreadas aos autos, a pretensão inicial merece prosperar. A materialidade restou comprovada ante o auto de prisão em flagrante (fls. 5/6), boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), laudos de constatação provisória (fls. 41/46) e de objeto (fls. 167/169), além do exame químico-toxicológico de fls. 170/172, que constatou as presenças de tetrahidrocannabinol (THC) e de cocaína nas amostras analisadas. A autoria também é certa. Na fase extrajudicial os acusados exerceram o direito constitucional ao silêncio (fls. 9/10). Em juízo o réu GUSTAVO disse ter 23 anos de idade, ter três filhos menores, morar em casa alugada, trabalhar como ajudante de soldador, com renda aproximada de R\$ 1.400,00, não conhecer as testemunhas arroladas e nunca ter sido preso e processado criminalmente. Já foi absolvido no Estado da Bahia de um homicídio. Sobre os fatos declarou que estava no tráfico de fato. Ficou desempregado e seus filhos dependiam de sua ajuda. Não teve

outra opção. A casa era sua. Cleiton não teve participação alguma nos fatos. Conhecia ele da rua, do salão de barbeiro. Trabalhava sozinho no tráfico. Cleiton tinha algumas drogas consigo, que era para seu próprio uso. Tinha o mesmo tipo de droga que Cleiton. O réu CLEITON não compareceu ao ato e foi declarado revel. Márcio Eric Alves Feitoza, policial militar que participou da ocorrência, afirmou que na data dos fatos, no início da tarde, estava em companhia de seu colega de farda realizando patrulhamento pela área conhecida como local de venda de entorpecentes, ocasião em que avistaram os réus caminhando e, ao notarem a presença da equipe policial, passaram a andar pelo lado oposto de onde inicialmente iam, levantando suspeitas, acarretando em busca pessoal a ambos. No interior das vestes de GUSTAVO foram localizadas duas porções de maconha e cem reais em dinheiro e, com CLEITON, também duas porções de maconha. Indagados, confirmaram sobre as drogas que portavam e que estavam comercializando. GUSTAVO disse que no interior de sua casa, localizada a alguns metros do local da abordagem, havia mais drogas, tendo franqueado a entrada dos policiais, que localizaram 952 pedras de crack, 15 porções de cocaína, 142 porções de maconha, R\$ 60,00 (sessenta reais) e radiocomunicadores com a respectiva base (fls.7). Em juízo relatou que estava em patrulhamento e a mudança abrupta de direção do abordados motivou a abordagem. Em busca pessoal havia com Gustavo duas porções e dinheiro. Com o outro também uma pequena porção. Ambos confirmaram que faziam o trafico nas imediações. Gustavo informou que em sua residência havia entorpecentes para tráfico. Dirigiram-se para lá, cerca de 80m do local, e Gustavo apresentou um saco preto com mais droga, variada. Radios comunicadores e carregadores também foram apreendidos. Não conhecia os envolvidos antes dos fatos. O local é próximo ao ponto de trafico. Gustavo disse ser da Bahia e que o outro abordado trabalhava com ele no tráfico. Esclareceu que a residência era habitável, com objetos pessoais do réu. Tinham mais casas no local. As drogas estavam em uma sacola preta em cima ou próximo da cama. A quantidade era considerável. Quando viu os acusados na via pública eles estavam juntos e quando viram a viatura mudaram abruptamente de direção. Se o réu não tivesse informado a residência não saberia da droga no local. Depois da busca pessoal e ao ser indagado o que fazia o Gustavo confirmou que praticava o tráfico e ao perguntar sobre mais droga confirmou que em sua casa havia mais drogas. Na mesma esteira o depoimento extrajudicial do também policial militar Pablo Carlos Renteiro (fls. 8), que em juízo contou que estava em patrulhamento próximo ao local conhecido por comercialização de trafico de entorpecentes e avistaram dois indivíduos. Eles perceberam a viatura e mudaram a direção. Fez busca pessoal e com Gustavo encontrou duas porções e R\$ 100,00. Com Cleiton duas porções de entorpecente. Indagados confirmaram o comércio de entorpecentes. Gustavo disse que na residência dele havia mais. Foram até o local. Gustavo autorizou a entrada e na casa mais droga foi encontrada, além de dois radios comunicadores e base para carregar. A casa era de Gustavo, que informou que Cleiton era seu funcionário na venda de entorpecentes. Não conhecia os envolvidos antes dos fatos. Os dois caminhavam juntos. Gustavo foi colaborativo. É importante salientar que a lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos. Aliás, nem teria sentido conferir-lhes a lei determinada tarefa para depois, quando viessem prestar contas de sua atuação, negar-lhes valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não dizem a verdade: "É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte" (STJ, Sexta Turma, AgRg no Ag 1158921/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julg. 17/05/2011, DJe 01/06/2011); "O depoimento de policial obedece os mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional" (TJSP, RT 752/586); "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,

não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18/02/97, DOU de 11/04/97, p. 189); "Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário é de idoneidade destas testemunhas, ainda mais quando os seus depoimentos são seguros precisos e uniformes desde a sede inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (TJSP, RT 614/275); "Os policiais não são proibidos de prestar depoimento nos processos de cuja fase policial tenham participado, seja efetuando a prisão do agente, seja apreendendo o objeto do crime. De outro lado, a declaração de inidoneidade é específica e não genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas, devendo ser alegada e demonstrada em cada caso" (TJMG, RT 604/407). Há de se levar em conta, também, que os acusados e os policiais não se conheciam até então, de forma que estes não tinham motivos para acusá-lo leviana e gratuitamente. A partir do contexto probatório extrai-se que as testemunhas prestaram depoimentos coesos e convergentes, reafirmando as declarações prestadas na fase policial, tornando seguro um decreto condenatório. E, não demonstrou a Defesa eventual motivo que os policiais teriam para mentir em juízo deixando, assim de se desincumbir de seu ônus (artigo 156, do Código de Processo Penal), destacando que eventuais e pequenas contradições entre os depoimentos, sequer existentes na hipótese, não são capazes de infirmar a lisura do trabalho policial. Nesse sentido: "PROVA - Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato" (TACrimSP - Ap. nº 583.153/2 - 7ª Câ. - Rel. José Habice - J. 05.04.90 - RJDTACRIM 6/78). É preciso ficar claro que a inexistência de testemunhas civis e 'eventuais compradores' no ato da prisão em flagrante não o invalida, cumprindo ressaltar que em delitos da espécie, como cediço, ainda que populares presenciem a atividade criminosa, estes não querem se identificar com medo de represálias por parte dos criminosos. Dentro desse quadro, os depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, repita-se, foram harmônicos e convergentes, levando à certeza da autoria. Sendo assim, a variedade, a quantidade e nocividade das drogas apreendidas, a forma como embaladas, o fato de o local da apreensão dos réus ser conhecido dos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, bem como o depoimento seguro prestado pelas testemunhas, levam à certeza de que os réus traficavam drogas na ocasião. Nesse ponto, em que pese tenha o réu Gustavo tentado tirar a responsabilidade do corréu e amigo Cleiton pelos fatos dos quais acusados, é certo que ambos estavam juntos na ocasião e, conforme depoimentos das testemunhas, eles afirmaram trabalhar juntos no comércio ilícito de drogas. Ademais, não se pode ignorar que Cleiton declinou como seu endereço exatamente o mesmo de Gustavo, ou seja, aquele em que as drogas foram encontradas (fls. 9 e 118), lembrando que a testemunha Márcio declarou textualmente que as drogas estavam em um saco em fácil visualização ("em cima ou próximo da cama"). Destaca-se que o crime de tráfico de entorpecente é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário, pelo que as simples condutas dos réus, consistentes em "trazer consigo" e "ter em depósito" as substâncias entorpecentes, já são suficientes para caracterização do delito: "Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para esta

destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado" (TJSP - Apel. Crim. nº 990.09.088010-4 - 5ª Câmara Criminal - Campinas - v.u. - j. 03.09.09 - Rel. Des. Pinheiro Franco). No mesmo sentido: "O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663); "Não é indispensável à prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (RT 729/542); "Cabe ressaltar que para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária a prova flagrante do comércio ilícito, sendo suficientes os elementos indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da prisão para evidenciar tal atividade ilícita". (TJ/SP - Apel. Crim. nº 990. 09.235417-5 - 14ª Câmara Criminal - v.u. - j. 11.03.10 - Rel. Des. Fernando Torres Garcia). Ressalta-se que a considerável quantidade e variedade de entorpecente, além da forma como se deu sua apreensão demonstram a traficância e não autorizam eventual classificação da conduta como simples consumo pessoal (artigo 28, da Lei nº 11.343/06): "DESCCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE USO - Inadmissibilidade - Quantidade e diversidade de entorpecentes - Conjunto probatório suficiente para ensejar o decreto condenatório - Inexistência de prova segura que autorizasse decretar nova definição jurídica da conduta." (TJSP, 16ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 990.08.080898-2, Des. Rel. Leonel Costa, j. 28/04/09). E o fato de os acusados eventualmente afirmarem que são usuários de droga, o que não se vislumbra, não é suficiente para a desclassificação do delito de tráfico, sendo, repita-se à exaustão, a condenação de rigor. Vale destacar, ainda, que a condição de usuário não é incompatível com a de traficante: "(...) a mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se valem dessa mercancia ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a outra." (TJSP, AC nº 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França Carvalho, j. 05/04/2018). "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP RJTJSP 101/498); "Importante consignar que o fato de o acusado ter declarado que era usuário de drogas não afasta sua condição de traficante, uma vez que os usuários, frequentemente, também passam a comercializar entorpecentes, justamente para obter dinheiro e garantir o vício e o próprio sustento, acrescentando-se, por oportuno, que uma conduta não exclui a outra" (TJSP; 9ª Câmara Criminal, Ap. n.º 0001866-59.2015.8.26.0635, Rel. Sérgio Coelho, j. em 31.03.2016); "Nenhuma incompatibilidade existe entre o tráfico de entorpecente e o vício. Ao contrário. Em regra, vivem associados" (RT 411/104). Cabe observar, nesse passo, que a apreensão de não desprezível quantidade de substância entorpecente, além da circunstância de estar separada em unidades diferentes ou dividida em porções, conduz à segura conclusão de que se destina ao comércio ilícito, e não ao uso próprio. Destarte, comprovadas a autoria e a materialidade, inexistindo causa de exclusão da ilicitude, a ação penal é procedente, amoldando-se a conduta praticada pelos réus à figura típica prevista no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, razão pela qual passo a individualmente dosar as penas. a) Em relação ao réu Gustavo Torres dos Santos - Sopesados os elementos norteadores do art. 59, do Código Penal e em observância ao disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, que autoriza que o magistrado considere na primeira fase de dosimetria a natureza do entorpecente, a quantidade, a personalidade e a conduta social do agente, de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal (v.g. STF, HC nº 96.655, rel. Min. Cármen Lucia; STF, HC nº 107.784, rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, HC nº 237.837, rel. Min. Laurita Vaz; STJ, HC nº 235.524, rel. Min. Jorge Mussi; STJ, HC nº 223.447, rel. Min. Laurita Vaz; STJ, HC nº 179.086, rel. Min. Gilson Dipp). No mesmo sentido: "REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO

LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. 1. Na fixação da pena-base de crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como ocorre na espécie, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas.

2. Na espécie, a reprimenda de piso acima do mínimo legal, em razão da natureza e a excessiva quantidade do estupefaciente apreendido, encontra-se devidamente justificada e proporcional às especificidades do caso versado. [...] 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 585.375/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe 27/3/2017); O réu é primário e não possui antecedentes criminais (fls. 58 e 61), contudo, na hipótese, foi localizado com "crack" e cocaína, entorpecentes de alto poder viciante, que causam dependência física e psíquica, mesmo que utilizados apenas uma única vez, motivo que enseja uma maior reprimenda, pois seria desarrazoado punir aquele que vende "maconha" na mesma medida daquele que vende entorpecente altamente viciante, que além de causar um impacto muito maior na saúde do usuário, ainda repercute na sociedade e na família, somado ao fato de corroborar com a prática delitiva daqueles que não possuem condições financeiras de sustentar o vício. Segundo o entendimento de Guilherme de Souza Nucci, "A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude de sua utilização. Estes fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado" (in Leis penais e processuais penais comentadas, 4ª edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 378). No mesmo sentido, defende Renato Brasileiro de Lima que "Como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não se pode equiparar a conduta daquele que é preso com um quilograma de maconha com a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já que esta droga tem um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado que aquela" (in Legislação criminal especial comentada, 2ª edição, JusPODIVM, 2014, p. 787). Registre-se que a cocaína é considerada um dos entorpecentes mais nefastos e viciantes, o que traz maiores danos à saúde pública, sendo de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por ser proporcional à quantidade e natureza. Assim, ponderando tal circunstância (natureza), fixo a pena-base com o acréscimo de 1/6 (um sexto), ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Quanto à fração a ser aumentada, vale destacar não haver previsão legal valorando o quantum, ficando a critério do magistrado analisando o caso concreto: "o magistrado fixa a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STJ, AgRg no REsp nº 143.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). Prosseguindo, nos termos do artigo 68, do Código Penal, retorno a reprimenda ao mínimo legal, considerando a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea. Ausentes circunstâncias agravantes. Presente, porém, a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diminuo a pena em 1/8 (um oitavo), resultando em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa. Ainda que se reconheça seja o réu primário e não exista prova de que se dedique às atividades delituosas, nem integre organização criminosa, justifica-se a diminuição apenas em 1/8 (um oitavo) em razão da variedade e da considerável quantidade da droga encontrada em seu poder (TJSP, Apelação nº 01049362.3/2, Des. Rel. Silveira Lima, j. 12/09/2007). Esta pena torna-se definitiva, tendo em vista a inexistência de outras causas de aumento e de diminuição. O valor do dia-multa deve ser calculado nos termos do artigo 43, da Lei nº 11.343/06, sendo fixado em um trinta avos do

salário mínimo vigente à época do pagamento, tendo em vista a situação econômica do acusado. No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, c.c. art. 42, da Lei nº 11.343/2006, diante da pena definitiva estabelecida e considerando a quantidade total líquida de entorpecente apreendido, justificam o afastamento da substituição da pena e a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto. Precedentes: "(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea "c", parte final, do RISTJ, e na Súmula 568/STJ, conheço do agravo para dar provimento parcial a o recurso especial, para aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no patamar de 2/3, redimensionando a pena da agravante para 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão e pagamento de 227 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, mantidos os demais termos da condenação." (STJ - Agravo em Recurso Especial nº 1743264-SP (2020/0208712-9), Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em: 25/09/2020. - grifos nossos. Ressalta-se que, no presente caso, o redutor não foi concedido em grau máximo, tampouco foi fixado regime inicial fechado pela presente decisão, de modo que não há desrespeito ao quanto decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no HC nº 596.603-SP (item 4), o qual determina a não imposição de regime inicial fechado aos condenados por prática do crime de tráfico privilegiado. Afigura-se, no entanto, descabido falar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos ou "sursis", porque não recomendáveis (artigos 44, III, e 77, II, do Código Penal). Isto porque cuida de crime de natureza grave, de acentuada reprovabilidade e cujas circunstâncias e consequências impedem a substituição, sob o risco de a retribuição estatal ao ilícito tornar-se inócua. Em outras palavras, nem seria razoável que o réu, condenado por traficar entorpecentes extremamente nocivos à saúde humana, a desestabilizar o seio familiar e a vida em sociedade, venha a receber tratamento similar àquele agente que perpetra um delito de menor potencial ofensivo (TJSP, Apelação Criminal nº 1501495-39.2019.8.26.0228, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ivana David, j. 15/09/2020). Vale lembrar que o chamado tráfico "privilegiado", previsto no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, não é um tipo penal autônomo menos grave, mas sim causa de diminuição de pena, sendo certo que a minorante não tem o condão de alterar o próprio tipo penal do tráfico de drogas que, frisa-se, é crime grave. A substituição, se deferida, faria com que a pena privativa de liberdade aplicada perdesse consideravelmente a sua força retributiva e preventiva, diante do gravíssimo delito de tráfico de drogas, levando em conta as especificidades do caso, como quantidade das drogas apreendidas. Ademais, não vislumbro socialmente recomendável a reinserção de traficantes ao convívio social, indicando-lhes instituições públicas (escolas, repartições públicas, centros de saúde etc) para prestar serviços comunitários. Ausente, portanto, o requisito do inciso III, do art. 44 do Código Penal (suficiência da substituição). O crime, frisa-se, é de especial gravidade, consistindo em causa ou consequência da prática de outros tão ou mais graves e intimamente ligados com a criminalidade violenta e com a desestruturação de inúmeras famílias. Os efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas acarretam profundas feridas na sociedade atual, revelam a postura indiferente adotada pelo agente em relação à saúde pública e ao bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos vão de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, qual seja, "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente". Assim, embora tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível na espécie, uma vez que seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal. Nesse sentido: "(...) Por sua vez, a quantidade, diversidade e natureza das drogas constituem circunstâncias concretas que desnudam um elevado grau de culpabilidade, a impor o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. O que também obsta a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44, I e III, do Código Penal), benefício, de resto, incompatível com a quantidade das sanções.(...)" (TJSP, 14ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1503722-19.2017.8.26.0536, Rel. Laerte Marrone, j. 30/01/2020); "(...) a gravidade concreta da conduta do apelante, decorrente da quantidade de droga

capaz de atingir um número não desprezível de usuários, revela a sua elevada danosidade social, a revelar óbice à substituição da pena corporal por restritivas de direitos, máxime porque estas não se mostram suficientes e socialmente recomendáveis (art. 44, III, CP). (...)” (TJSP, 13ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 0000208-34.2016.8.26.0483, Rel. Moreira da Silva, j. 03/08/2017); “(...) No entanto, com a devida vênia, o traficante, seja de pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para inicialmente cumprir a pena infligida de outra forma que não encarcerado. Ora, não se mostra razoável que o traficante, condenado por delito equiparado a hediondo (artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal) venha a receber tratamento similar ao agente que perpetra um delito de menor potencial ofensivo. Em suma, não se mostra adequada a substituição da pena privativa

de liberdade por restritiva de direito em casos de tráfico de entorpecente, uma vez que tal medida atenta contra a efetividade do processo penal na aplicação do justo concreto, atingindo frontalmente o caráter retributivo da reprimenda e a dimensão material ou substancial do due process of law. (...) E, na espécie, como foram apreendidas 16 gramas de cocaína, droga de grande potencial ofensivo, a aplicação de pena alternativa encontra óbice na exegese do artigo 44, III do Código Penal, sendo insuficiente como resposta à culpabilidade do agente, aos motivos e às consequências do exercício da mercancia” (TJSP, Habeas Corpus nº 0049710-72.2012.8.26.0000, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Euvaldo Chaib). b) Em relação ao réu Cleiton dos Santos Silva - Sopesados os elementos norteadores do art. 59, do Código Penal e em observância ao disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, que autoriza que o magistrado considere na primeira fase de dosimetria a natureza do entorpecente, a quantidade, a personalidade e a conduta social do agente, de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal (v.g. STF, HC nº 96.655, rel. Min. Cármen Lucia; STF, HC nº 107.784, rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, HC nº 237.837, rel. Min. Laurita Vaz; STJ, HC nº 235.524, rel. Min. Jorge Mussi; STJ, HC nº 223.447, rel. Min. Laurita Vaz; STJ, HC nº 179.086, rel. Min. Gilson Dipp). No mesmo sentido: "REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. 1. Na fixação da pena-base de crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como ocorre na espécie, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas. 2. Na espécie, a reprimenda de piso acima do mínimo legal, em razão da natureza e a excessiva quantidade do estupefaciente apreendido, encontra-se devidamente justificada e proporcional às especificidades do caso versado. [...] 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 585.375/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe 27/3/2017); O réu é primário e não possui antecedentes criminais (fls. 57 e 60), contudo, na hipótese, foi localizado com "crack" e cocaína, entorpecentes de alto poder viciante, que causam dependência física e psíquica, mesmo que utilizados apenas uma única vez, motivo que enseja uma maior reprimenda, pois seria desarrazoado punir aquele que vende "maconha" na mesma medida daquele que vende entorpecente altamente viciante, que além de causar um impacto muito maior na saúde do usuário, ainda repercute na sociedade e na família, somado ao fato de corroborar com a prática delitiva daqueles que não possuem condições financeiras de sustentar o vício. Segundo o entendimento de Guilherme de Souza Nucci, "A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude de sua utilização. Estes fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado" (in Leis penais e processuais penais comentadas, 4ª edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 378). No mesmo sentido, defende Renato Brasileiro de Lima que "Como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a

substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não se pode equiparar a conduta daquele que é preso com um quilograma de maconha com a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já que esta droga tem um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado que aquela" (in Legislação criminal especial comentada, 2ª edição, JusPODIVM, 2014, p. 787). Registre-se que a cocaína é considerada um dos entorpecentes mais nefastos e viciantes, o que traz maiores danos à saúde pública, sendo de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por ser proporcional à quantidade e natureza. Assim, ponderando tal circunstância (natureza), fixo a pena-base com o acréscimo de 1/6 (um sexto), ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Quanto à fração a ser aumentada, vale destacar não haver previsão legal valorando o quantum, ficando a critério do magistrado analisando o caso concreto: "o magistrado fixa a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STJ, AgRg no REsp nº 143.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). Prosseguindo, nos termos do artigo 68, do Código Penal, mantenho a pena no patamar fixado, considerando a ausência de qualquer circunstância atenuante que possa ser aplicada no caso concreto. Ausentes circunstâncias agravantes. Presente, porém, a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diminuo a pena em 1/8 (um oitavo), resultando em 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 7 (sete) dias de reclusão e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa. Ainda que se reconheça seja o réu primário e não exista prova de que se dedique às atividades delituosas, nem integre organização criminosa, justifica-se a diminuição apenas em 1/8 (um oitavo) em razão da variedade e da considerável quantidade da droga encontrada em seu poder (TJSP, Apelação nº 01049362.3/2, Des. Rel. Silveira Lima, j. 12/09/2007). Esta pena torna-se definitiva, tendo em vista a inexistência de outras causas de aumento e de diminuição. O valor do dia-multa deve ser calculado nos termos do artigo 43, da Lei nº 11.343/06, sendo fixado em um trinta avos do salário mínimo vigente à época do pagamento, tendo em vista a situação econômica do acusado. No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, c.c. art. 42, da Lei nº 11.343/2006, diante da pena definitiva estabelecida e considerando a quantidade total líquida de entorpecente apreendido, justificam o afastamento da substituição da pena e a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto. Ressalta-se que, no presente caso, o redutor não foi concedido em grau máximo, tampouco foi fixado regime inicial fechado pela presente decisão, de modo que não há desrespeito ao quanto decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no HC nº 596.603-SP (item 4), o qual determina a não imposição de regime inicial fechado aos condenados por prática do crime de tráfico privilegiado. Tal como justificado em relação ao corréu Gustavo, afigura-se descabido falar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos ou "sursis", porque não recomendáveis (artigos 44, III, e 77, II, do Código Penal). Isto porque cuida de crime de natureza grave, de acentuada reprovabilidade e cujas circunstâncias e consequências impedem a substituição, sob o risco de a retribuição estatal ao ilícito tornar-se inócua. Em outras palavras, nem seria razoável que o réu, condenado por traficar entorpecentes extremamente nocivos à saúde humana, a desestabilizar o seio familiar e a vida em sociedade, venha a receber tratamento similar àquele agente que perpetra um delito de menor potencial ofensivo (TJSP, Apelação Criminal nº 1501495-39.2019.8.26.0228, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ivana David, j. 15/09/2020). Vale lembrar que o chamado tráfico "privilegiado", previsto no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, não é um tipo penal autônomo menos grave, mas sim causa de diminuição de pena, sendo certo que a minorante não tem o condão de alterar o próprio tipo penal do tráfico de drogas que, frisa-se, é crime grave. A substituição, se deferida, faria com que a pena privativa de liberdade aplicada perdesse consideravelmente a sua força retributiva e preventiva, diante do gravíssimo delito de tráfico de drogas, levando em conta as especificidades do caso, como quantidade das drogas apreendidas. Ademais, não vislumbro socialmente recomendável a reinserção de traficantes ao convívio social, indicando-lhes instituições públicas (escolas, repartições públicas, centros de

saúde etc) para prestar serviços comunitários. Ausente, portanto, o requisito do inciso III, do art. 44 do Código Penal (suficiência da substituição). O crime, frisa-se, é de especial gravidade, consistindo em causa ou consequência da prática de outros tão ou mais graves e intimamente ligados com a criminalidade violenta e com a desestruturação de inúmeras famílias. Os efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas acarretam profundas feridas na sociedade atual, revelam a postura indiferente adotada pelo agente em relação à saúde pública e ao bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos vão de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, qual seja, "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente". Assim, embora tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível na espécie, uma vez que seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal. Visando a